

1500951-38.2021.8.26.0630

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Seqüestro e cárcere privado

Magistrado: André Forato Anhê

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... que o réu apresenta duas reincidências simples (Proc. 0002126-68.2012.8.26.0142, por tráfico, e 0002472-19.2012.8.26.0142, por porte ilegal de arma; vide fls. 262/264, ambos em cumprimento de pena).

Considero a majoração de 1/6 para cada reincidência (para a simples, aplica-se 1/6; para a específica, 1/4); logo, implicando o aumento de 2/6 (= 1/3).

Assim, aplicada aqui a fração ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Ímola 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500951-38.2021.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500951-38.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Seqüestro e cárcere privado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2322364/2021 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AILTON CESAR GONÇALVES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Forato Anhê

Vistos.

AILTON CESAR GONÇALVES DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo como incurso na pena do artigo 148, § 1.º, incisos I e IV, e no artigo 147, ambos cumulados com o art. 61, inciso II, "f", todos do Código Penal (CP) e todos com a incidência dos artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), cumulados na forma do artigo 69 do Código Penal (CP).

Consta da inicial acusatória que, a partir da madrugada do dia 26 de novembro de 2021 até próximo ao meio-dia do mesmo dia, na Rua Frederico Alves da Costa, n.º 473, Jardim Nova Hortolândia, nesta cidade e comarca de Hortolândia, o acusado, prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação, e na forma da lei

específica, privou a sua companheira, J.S.S., adolescente, de sua liberdade, mediante cárcere privado.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de local e fato, o acusado, prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação, e na forma da lei específica, ameaçou a sua companheira, J.S.S., adolescente, de causar-lhe mal injusto e grave.

O réu foi detido em flagrante e responde ao presente processo preso preventivamente.

A denúncia foi recebida em 9/12/2021 (fls. 84/86), sobrevivendo a citação do réu e, na sequência, ofertando-se a regular resposta à acusação, a fls. 102/105.

Não foram reconhecidas hipóteses de absolvição sumária, mantido o recebimento da denúncia por decisão de fls. 161/165.

Em audiência instrutória foram ouvidas a vítima, mediante depoimento especial, os guardas municipais e a irmã e a genitora da vítima. Ao fim, o réu foi interrogado.

A acusação e a defesa manifestaram-se em sede de memoriais.

A promotoria postulou a condenação na forma da denúncia, considerando cabalmente provadas a materialidade e a autoria delitivas (fls. 293/308).

A folhas 312/336, vieram as alegações de defesa.

A defesa requereu, preliminarmente: a) a declaração de ilicitude das provas, sob a alegação de que foi ilegal a entrada dos guardas municipais na residência, porque não havia fundadas suspeitas ou estado de flagrante para o ingresso; b) a ausência de justa causa para propositura da ação penal, pois não haveria individualização das condutas com todas as características que demonstrassem indícios de autoria.

No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória, sob os seguintes argumentos:

- (a) A vítima declarou que ocorreu apenas uma discussão motivada por ciúmes, que suas declarações na polícia são inverossímeis e foram retratadas por ela no depoimento especial em Juízo e em carta manuscrita.
- (b) O réu guardou a chave, porque J. estava com crise de ansiedade, causada pela discussão, e não teria condições de sair sozinha, pela sua segurança.
- (c) A vítima tem o hábito de descartar coisas pela janela e, num momento de descontrole e raiva, jogou o bilhete pela janela, todavia afirmou posteriormente que não estava sob cárcere privado.
- (d) As declarações dos guardas municipais apresentam pontos contraditórios, com relação à origem da denúncia (se teria sido anônima ou não) e à quantidade de pessoas que acompanharam as diligências (se um morador teria ou não acompanhado).
- (e) No interior do apartamento não havia indícios de crime em andamento. O acusado e a vítima estavam deitados na cama, no quarto, abraçados, dormindo, no momento da entrada dos guardas no apartamento. E a vítima não estava amarrada, machucada, nem foi ameaçada, tinha celular, e ambos tinham chave de entrada no imóvel.
- (f) A testemunha Tainara, irmã da vítima, demonstrou que não gosta do acusado e que ele é seu inimigo declarado, logo haveria interesse na sua condenação.
- (g) A genitora da vítima declarou que o acusado era bom genro e boa pessoa. A vítima declarou que deseja a liberdade do acusado; caso tivesse ocorrido crime, não a desejaria.

Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, e teceu aspectos concernentes ao cálculo de pena e à fixação de regime de cumprimento.

Por fim, postulou a isenção da pena de multa, a concessão de justiça gratuita e a concessão de liberdade provisória.

É o relatório.

DECIDO.

Preliminarmente (em preliminar de mérito), a entrada na residência pelos guardas municipais foi legal, pois se tratava de flagrante delito de cárcere privado, crime de natureza permanente, que se protraí no tempo, e, ainda, o ingresso era autorizado para prestar socorro à vítima, mostrando-se absolutamente dispensável a autorização judicial – e muito menos a do réu – para o ingresso na residência, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Afirma o Supremo Tribunal Federal (repercussão geral – Tema 280): “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

E havia elementos indicativos iniciais do delito de cárcere privado (exteriorização do flagrante), já que ao chegaram ao local, os guardas 1) viram o bilhete de socorro; 2) receberam informações de que havia sido jogado pela janela e recolhido por um transeunte que viu a vítima acenando da janela; 3) chamaram e bateram na porta do apartamento, mas não foram atendidos; 4) foram informados que o casal estava no interior do apartamento, sendo lícito, pelas circunstâncias acima, o acesso ao domicílio do autor da infração penal, prescindindo para tanto o mandado judicial (tendo em vista o delito em cárcere privado em andamento naquele momento e a necessidade imediata de prestar socorro a vítima).

Quanto à alegação de ausência de justa causa para o exercício da ação penal, o requerimento não prospera.

Conforme exposto acima, desde o flagrante havia indícios consistentes de autoria e de materialidade, e as declarações prestadas em solo policial pela vítima e guardas municipais, analisadas a seguir, já indicavam presença do dolo previsto para o delito do artigo 148 do Código Penal, a justificar a propositura da ação penal.

No mérito, com relação ao delito de cárcere privado, a materialidade se põe indiscutível.

Vem provada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), pelas declarações iniciais (fls. 2/7), pelo BO-PC (fls. 11/14), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), pela cópia do bilhete de socorro (fls. 17) e pelo relatório policial (fls. 74).

Também a autoria se põe comprovada, sem dúvida alguma, demonstrada pelos depoimentos judiciais, confirmatórios dos depoimentos preliminares.

Os depoentes confirmaram a ação do réu conforme o descrito pela acusação.

Interrogado na delegacia, Ailton declarou que mantinha relacionamento com J.S.S. havia cerca de um ano, com o consentimento da mãe dela, e que havia três meses moravam juntos no apartamento dele. Disse que J. era bipolar, “cortava-se” às vezes, e, no dia dos fatos, ela teve um surto de ciúmes, agrediu-o com chutes, murros, feriu-o com uma lixa de unha, bem como o queimou com a ponta de um cigarro. Disse que, para se proteger, apenas segurou J., não a agrediu, nem a ameaçou. Nega

que tenha trancado o apartamento para impedi-la de sair do local. Não atenderam os guardas, pois estavam dormindo no quarto, ventilador ligado, porta fechada, e ambos não ouviram nada.

Em Juízo, o acusado acrescentou que não impediu a vítima de sair do apartamento, pois ela tinha cópia da chave e poderia sair à hora em que quisesse, mas no dia não sabia se ela estava com sua chave, bem como disse que ela tinha celular. Não conhecia os guardas. Naquele dia, J. não quis romper o relacionamento. Ficou sabendo apenas na delegacia do teor do bilhete de socorro. Teve desentendimentos com Tainara, irmã da vítima. Tinha um bom relacionamento com a genitora da vítima.

Todavia, diante da prova oral judicial, em harmonia com as provas da apuração preliminar, a condenação se impõe.

A vítima J. S. S., adolescente com 16 anos de idade na época dos fatos, foi ouvida na delegacia de polícia, acompanhada de sua irmã Tainara Aparecida da Silva, ocasião em que prestou minucioso depoimento.

Declarou que havia cerca de um ano mantinha relacionamento com o acusado Ailton, ambos moravam na casa da mãe dela, contudo, cerca de três meses antes dos fatos, o casal decidiu se mudar para o condomínio Peruíbe.

Narrou que Ailton era agressivo e o relacionamento não estava harmonioso. Havia sofrido agressões por parte de Ailton em datas pretéritas, mas nunca registrou as ocorrências na delegacia.

Disse que no dia dos fatos, na madrugada, resolveu que iria pôr fim ao relacionamento e iria embora do apartamento para a casa de sua mãe; porém, Ailton não aceitou o término, e passou a ameaçá-la de morte, dizendo que ela não iria a lugar algum, e, caso saísse do local ou chamasse algum familiar ou a polícia, mataria a ela; e chegou a pegar faca para ameaçá-la.

Afirmou que Ailton trancou o apartamento onde moram, pôs as chaves no bolso, e não deixou que a declarante se comunicasse com quem quer que fosse, pois não tinha telefone. Impediu-a de sair do local, novamente a ameaçando caso o fizesse; somente a janela da sala ficou aberta, mas moram no 2º andar e não havia como pular.

Nisso, ocorreu uma discussão, o acusado insistia que eles reatassem o relacionamento, ela se negava, e, quando tentava sair, o réu a ameaçava.

Asseverou que, em dado momento de distração de Ailton, conseguiu escrever um bilhete com "lápis de olho" em um pedaço de papel, com os dizeres: "moça, chama a polícia por favor", e o jogou pela janela da sala para fora de seu apartamento, para que uma mulher que passava lá fora percebesse o que estava ocorrendo, visse o bilhete e acionasse ajuda.

Afirmou que ficou privada de sua liberdade, entre a madrugada e a chegada da equipe da Guarda Municipal, por volta das 12 h, ou seja, por quase sete ou oito horas.

Quando os guardas chegaram, ela estava no quarto com Ailton, e ele não atendeu ao chamado dos guardas. O acusado determinou que ela ficasse quieta, mesmo dizendo a ele que gritaria na janela pedindo ajuda, e ele a ameaçou dizendo que "se você gritar, você vai ver o que vai acontecer".

Disse que apenas conseguiu se libertar quando os guardas forçaram a porta e entraram na moradia.

Não teve lesões, pois AILTON não a agrediu nesta data, porém sentiu-se ameaçada.

Por fim, solicitou medidas protetivas em seu favor.

A vítima foi novamente ouvida em sede de depoimento especial, por intermédio do psicólogo judicial, e, quando questionada acerca dos fatos, alterou parcialmente a declaração anterior.

Preferiu depor sem a presença do acusado.

Confirmou que a discussão começou cedo, por causa de ciúmes, todavia disse que não houve ameaça, nem agressões por parte do acusado.

Contou que começou a passar mal, teve crise de ansiedade e queria ir embora sozinha, mas Ailton, vendo seu estado de nervosismo, disse que não a deixaria sair desacompanhada, trancou a porta e ficou com a chave.

Negou que Ailton tivesse a ameaçado, usado faca ou arma.

Afirmou que estava nervosa com Ailton, por isso escreveu um bilhete solicitando ajuda, mas pensou melhor e decidiu amassar e descartá-lo-pela janela, sem a intenção de que alguém o encontrasse. Horas mais tarde, conversaram e se reconciliaram.

A polícia demorou para chegar, cerca de 7 horas depois. Não abriram a porta aos guardas porque ela e Ailton não os ouviram chamar ou bater. Estavam deitados na cama, no quarto, com a porta fechada e o ventilador ligado.

Declarou aos guardas que Ailton não a deixava sair do apartamento.

Afirmou que desde a prisão não teve mais contato com Ailton, mas deseja que ele seja solto, pois é trabalhador, e que naquele dia ela errou por ter jogado o bilhete pela janela.

Disse que procurou o advogado Dr. Rodrigo para o Ailton, a pedido da mãe e da família dele, que moram longe.

Confirmou que o relacionamento tinha muita briga.

Passou-se, em seguida, à inquirição dos guardas municipais, que confirmaram as declarações prestadas em solo policial.

O guarda municipal Elias Pereira da Silva, em Juízo, afirmou que a equipe recebeu chamado da Central, informando que no local uma pessoa estaria sob cárcere privado e pedindo ajuda. Na portaria, entregaram um bilhete que a vítima jogou pela janela, o qual dizia "moça, chama a polícia" e informaram de qual apartamento havia sido jogado.

Sua equipe foi até o local, bateram várias vezes na porta do apartamento indicado, mas não houve resposta. Estava trancada, e forçaram a porta, entraram, dirigiram-se até o quarto, onde visualizaram o casal deitado na cama. Ela estava encostada na parede, e Ailton ao seu lado, com braços por cima dela.

Ailton se levantou e fizeram a contenção, algemando-o. Localizaram a chave do apartamento no seu bolso.

Entrevistaram em particular a vítima, a qual afirmou que Ailton não aceitava a separação, por isso não a deixava sair. Desde a madrugada queria ir embora, até que teve a ideia de escrever o bilhete e jogá-lo pela janela.

Durante a abordagem, Ailton estava calmo; a vítima aparentava nervosismo, e com

dificuldades para falar. Ela disse que Ailton a ameaçou verbalmente, mas negou agressões físicas. Não se recordou de ela ter mencionado algo sobre arma ou faca. A vítima contou que em datas anteriores ocorreram agressões, mas nunca fez comunicação à Polícia, porque Ailton sempre a ameaçava.

Disse que não conhecia o acusado, nem a vítima. Viu o bilhete e entregou na delegacia.

O depoimento do guarda municipal Bruno Custódio complementou o dito pelo guarda Elias, na medida em que confirmou o chamado da Central acerca de um cárcere privado em andamento e um bilhete pedindo socorro atirado pela janela, levado à portaria do condomínio.

Afirmou que no local indicado pela portaria bateram na porta, mas não foram atendidos, até que receberam informação de que o casal estava lá dentro. Decidiram forçar a entrada. No interior do quarto, viram o réu e vítima deitados na cama. Ele, com o braço sobre dela. Ela, assustada, titubeava, com dificuldade para falar.

Separada do companheiro, disse que, após uma briga, Ailton a impediu de sair e a ameaçava de morte, por isso escreveu o bilhete pedindo socorro. Não demonstrou preocupação com a presença dos guardas, mas sim em sair dali o mais rápido possível.

Não se recorda de quem indicou que o casal estava no interior do apartamento. Não se lembra de ela ter mencionado faca ou outro objeto de ameaça.

A testemunha Landsteiner de Araújo e Silva, inquirida em Juízo, afirmou que é guarda municipal e também presidente da comissão que fiscaliza o síndico, além de atender esporadicamente a chamados ligados à área da segurança dentro do condomínio.

Recebeu informação que uma moradora avistou alguém jogar da janela um papel no chão, e chamá-la. Ela pegou o papel, leu o pedido de socorro e entregou-o na portaria, que ligou para ele e passaram as informações do apartamento.

Disse que leu o bilhete e chamou a Guarda Municipal. Acompanhou a ação da equipe que chegou, foram até o apartamento, e no local encontraram a moça e o rapaz. Ela confirmou estar encarcerada e que queria ir embora, mas o réu não permitia.

A testemunha Tainara Aparecida da Silva, irmã da vítima, em Juízo afirmou que o Ailton e J. brigavam muito. Antes, ela, sua irmã e Ailton moravam todos juntos na casa da mãe da vítima. Nessa época, via e ouvia as brigas do casal, mas quando questionava sua irmã, ela negava agressões e demonstrava que tinha medo dele. Certa vez, ouviu-o dizer à irmã: "é, se você falar alguma coisa, você sabe, né?; você já sabe, né?"

Disse que já viu marcas de agressão no braço da vítima. Já discutiu com Ailton, no dia em que o viu batendo em J.S.S. Tainara afirmou que não se dava bem com ele. Tentava orientar a irmã, mas ela não a escutava. Ailton tinha ciúmes de J., com relação às amigas e quando ela ia à escola. A irmã contou-lhe que o réu tinha o costume de tirar a chave da porta quando eles brigavam.

Acerca dos fatos, ligaram para que comparecesse na delegacia. No local, acompanhou e ouviu o depoimento da vítima. A irmã disse que havia brigado com o réu durante a madrugada e queria ir embora, mas Ailton não deixou, ameaçou-a com faca, chegou a apontá-la, e pegou a chave. Ela fez bilhete e jogou para uma mulher do lado de fora, que chamou a polícia. Contou que ele não a deixava sair, e que faria alguma coisa contra ela se saísse.

Na delegacia, sua irmã J. estava abalada, demonstrava tristeza, e dizia que não queria manter relacionamento com Ailton, não suportava suas atitudes em relação a ela. Já Ailton ficava todo o tempo pedindo perdão à vítima, na delegacia.

Claudia Aparecida da Silva, genitora da vítima, afirmou em Juízo que Ailton e sua filha moraram juntos na casa da família por cerca de 8 meses, até que se mudaram para o apartamento dele. Confirmou que J. as vezes tem crises de ansiedade. Disse que nunca viu o casal brigar, mas já ouviu vizinhos dizerem que eles brigavam, e que ele já tinha batido nela. A filha sempre negou agressões. Acerca dos fatos, a vítima contou-lhe o ocorrido, mas não se recorda. Disse que gostava de Ailton.

A ação procede, mas em parte.

Quanto ao delito de ameaça, previsto no artigo 147, caput, do CP, ocorreu a extinção da punibilidade pela decadência, nos termos do artigo 107, IV, do CP.

O crime de ameaça somente se procede mediante representação (art. 147, parágrafo único, CP) do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo (art. 24, CPP). Decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime (art. 103, do CP).

No caso em apreço, tratando-se de ofendida menor de 16 anos de idade à época dos fatos, necessária a representação de seu responsável legal para o processamento do delito de ameaça praticado contra a adolescente.

A vítima foi ouvida na delegacia acompanhada por sua irmã, todavia não foi oferecida a formal representação pela genitora nem pela irmã. A vítima também não ofertou representação. E, já decorrido prazo superior a 6 meses desde os fatos, ocorreu a decadência do direito de representação, logo a extinção da punibilidade pelo crime de ameaça é de rigor, nos termos acima.

Por outro lado, o delito do artigo 148 do CP (cárcere privado) restou devidamente comprovado, haja vista a robustez das provas materiais colhidas em inquérito e diante da consistência e coerência dos depoimentos prestados em audiência judicial.

A vítima narrou em solo policial, em detalhes, todo o ocorrido, sendo segura e categórica ao imputar os fatos ao acusado, afirmando que Ailton não aceitou o término do relacionamento, trancou a porta do apartamento, guardou a chave e ameaçou-a, inclusive apontando faca, caso tentasse ir embora ou falasse com alguém. Escreveu bilhete pedindo socorro e jogou-o pela janela, para uma moça que passava na hora. A polícia bateu na porta, Ailton ameaçou-a para ficasse deitada na cama e quieta. Os guardas entraram no apartamento, e contou-lhes que o acusado não a deixava sair do apartamento.

E a declaração da vítima pôde ser comprovada pelo bilhete de fls 17, com os dizeres: "MOÇA, CHAMA A POLÍCIA POR FAVOR", escrito a "lápis de olho", conforme dito pela vítima, indicando que foi feito às pressas, enquanto o acusado estava distraído, corroborando o fato de que estava sendo mantida sob cárcere privado, contra a sua vontade.

Em depoimento especial, em juízo, a vítima alterou parcialmente a versão dos fatos (embora sem desnaturar o crime de cárcere privado).

Narrou o cárcere privado (que durou cerca de 7 horas), mas tentou justificar a atitude de Ailton por trancar o apartamento, declarando que ele a impedia de sair do local, para resguardar sua segurança, pois estaria com crise de ansiedade.

Negou a ameaça com faca (mas a narrou na delegacia, e a irmã confirmou).

Igualmente, negou ter sofrido agressões em datas pretéritas, eram apenas discussões (testemunhas, porém, confirmaram em juízo que eram agressões; na delegacia a vítima assim também reportou).

Disse que na delegacia assinou sem ler o seu depoimento.

Afirmou, estranhamente, que descartou o bilhete pela janela, com a intenção de jogá-lo fora, e não para que alguém viesse em seu socorro.

Pois bem. Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, não raro as vítimas buscam amenizar, em Juízo, as declarações prestadas na delegacia, acerca da conduta do companheiro, motivada por culpa, dependência financeira e afetiva ou mesmo por pressões familiares, a indicar o ciclo de violência doméstica ao qual estão submetidas -- o que entendo restar demonstrado neste caso.

Conforme narrado pela própria vítima, Ailton era agressivo e o relacionamento não era harmonioso. Havia sofrido agressões por parte de Ailton em datas pretéritas. Guardas municipais também confirmaram que ouviram a vítima dizer que havia sido agredida anteriormente. Tainara, irmã da vítima, declarou que já presenciou brigas, agressão física e marcas no braço da ofendida. A genitora da vítima já ouviu vizinhos dizerem que eles brigavam, e que ele já tinha batido nela.

Ainda, após a prisão de Ailton, atendendo a pedido de familiares do réu, a vítima procurou pessoalmente advogado particular para patrocinar a defesa do acusado.

Escreveu carta no curso do processo, retratando-se das graves acusações prestadas na delegacia, dizendo que estava com raiva e com ciúmes e começou a "falar coisa em cima de coisa", das quais não se lembra (cf. fls. 107).

Prestou depoimento em juízo, justificando porque o réu trancou-a no apartamento.

E ainda afirmou em juízo que errou ao jogar o bilhete com pedido de socorro.

Disse que jogou bilhete de socorro pela janela como forma de descarte, e não com a intenção de que alguém chamasse a polícia, o que é pouco crível, já que, segundo testemunhas, acenou para que uma transeunte pegasse o bilhete. Caso contrário, seria impossível a Guarda Municipal encontrar o apartamento, pois o bilhete não indicava a unidade em que a vítima estava. Também escreveu o bilhete usando a palavra "MOÇA", a indicar que o redigiu rapidamente, assim que viu a mulher passando pelo local.

Este julgador não pode ignorar tais circunstâncias, demonstrativas de que a vítima se sente culpada pelos fatos que ocorreram, não conseguindo enxergar, no todo, a gravidade da situação e o abuso ao qual foi submetida, estando amarrada ao ciclo da violência doméstica.

Nesse sentido, já decidiu o e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Apelação criminal. Lesão corporal. Ameaça. Violência doméstica. Violência de gênero. Vítima. Depoimento. Necessário tomar redobrada cautela com depoimentos de vítimas que, em investigações processuais de casos de violência de gênero, buscam, de modo lacônico e inusitado, retratar-se de seus depoimentos anteriores, agora para favorecer indevidamente seus companheiros. São situações que deixam evidente que a segunda palavra da vítima não tem como ser acreditada, senão como uma frustrada tentativa de proteger - indevidamente, aliás - seu agressor de antes. Não se pode admitir que, aproveitando-se de uma cultura de impunidade, homens depois façam suas companheiras darem uma segunda e inverídica versão perante as

autoridades para, com isso, safarem-se de uma responsabilidade por sua injustificada conduta anterior. Há de se apreciar casos de agressão de gênero com todo o cuidado próprio que eles exigem, inclusive para a devida avaliação da prova quando ela indica com precisão que a segunda versão das vítimas nada mais faz que buscar proteger - indevidamente, com frequência - a pessoa de um agressor que, por ciúme ou mera prepotência, deixou no rosto da companheira as marcas de sua violência, há muito positivadas em laudo de exame de corpo de delito. Essa violência não diz respeito a uma mulher, mas a todas e a todos os humanos. Não tem como ser esquecida ou ignorada." (Apelação nº 0007042-09.2015.8.26.0606; rel. Des. Sérgio Manzina Martins, 2ª Câmara de Direito Criminal, j. 14.05.2018)

Assim, diante de uma nova versão dos fatos apresentada pela vítima de violência doméstica, faz-se necessária a tomada de cautela, e sua ponderação com os demais elementos probatórios colhidos nos autos, em busca da verdade real dos fatos, ainda mais quando se verifica interesse da vítima pela absolvição do acusado, conforme se depreende da carta manuscrita de fl. 107.

Embora o artigo 155 do Código de Processo Penal vede que o juiz fundamente sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, não há violação ao dispositivo legal "quando a condenação se apoia também em elementos de provas judicializadas, colhidas no âmbito do devido processo legal" (AgRg no Ag 1317430 - PE, 6.ª T., rel. Maria Thereza de Assis Moura, 02.08.2012, v.u.).

E, no caso sob análise, em que pese a vítima ter negado as ameaças e abrandado o cárcere privado, sua palavra em audiência judicial deve ser relativizada, pois as demais provas colhidas sob o contraditório e em Juízo corroboram sua narrativa em solo policial e os fatos contidos na denúncia.

Os guardas municipais, na delegacia e depois em juízo, sob o contraditório, confirmaram que, de posse do bilhete de socorro, bateram à porta, e, não atendidos, precisaram forçá-la para entrar no apartamento. No interior, encontraram a vítima e o réu deitados na cama, ele com braço por cima dela. Localizaram a chave do apartamento no bolso do réu. Separados, indagaram a ofendida, que, nervosa, confirmou que Ailton a impedia de sair do apartamento mediante ameaças.

A Defesa alega que as declarações dos guardas municipais apresentam pontos contraditórios, com relação à origem da denúncia (se teria sido anônima ou não) e à quantidade de pessoas que acompanharam as diligências (dúvida acerca de um morador ter acompanhado a entrada no apartamento).

As alegações defensivas não prevalecem.

Com relação à forma de comunicação da "denúncia", é incontroverso que foi realizada por ligação telefônica à Central da Guarda Municipal. Landsteiner disse que foi ele quem ligou. Os GMs Elias e Bruno disseram que a Central recebeu denúncia anônima. Ora, é provável que a Central repassou aos guardas municipais a ocorrência, sem ter identificado o denunciante, e os guardas tenham interpretado que foi anônima (como ocorre normalmente).

Já no tocante ao número de pessoas que acompanharam a diligência à porta do apartamento, é natural que, em razão do tempo decorrido e das inúmeras ocorrências semelhantes atendidas pelos guardas municipais, existam pequenas divergências nos depoimentos.

De todo modo, tratam-se de aspectos secundários, que não retiram a credibilidade dos depoimentos, tampouco a essência do narrado.

Os guardas municipais e a testemunha Landsteiner confirmaram o cárcere: o bilhete de socorro; a casa fechada; a chave no bolso do réu, a declaração da vítima de que

estava presa e sendo ameaçada e de que havia agressões anteriores. É o essencial e demonstra a ocorrência do crime imputado.

Pequenas contradições da prova testemunhal decorrem das próprias imperfeições humanas, e são irrelevantes quando as testemunhas concordam sobre pontos e circunstâncias essenciais, como aqui se deu.

Segundo Borges da Rosa: "Como dizem BINET, STERN, VARENDONCK, GORPHE, BANCELS e outros, os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eundem premeditatum sermonem, de que fala FLAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas" (Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª Ed., RT, 1982, pág. 322).

Nesse sentido destaco julgado do e. TJ-SP:

"Roubo simples tentado e ameaça - art. 157, caput, c.c. art. 14, II e art. 147, todos do CP Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Robusto conjunto probatório (...) - Aliás, ao contrário do que alega a defesa, apesar de haver divergências entre os depoimentos das testemunhas, isto em nada altera a segurança com a qual elas narraram os crimes, tratando-se de pequenas discrepâncias normais que decorrem naturalmente da narrativa pessoal de cada depoente (...)" (Apelação Criminal nº 1509240-70.2019.8.26.0228, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

Tainara, irmã da vítima, acompanhou o depoimento de J. e confirmou a declaração dada pela vítima na delegacia, de que Ailton pegou a chave, não a deixava ir embora e ameaçou-a com faca; de que fez bilhete e jogou para uma mulher do lado de fora, que chamou a polícia. Contou que ele não a deixava sair, e, se saísse, faria alguma coisa contra ela.

A irmã poderia até não ser a responsável legal da vítima para a vida civil, mas, naquele momento, concretamente e para aquele ato, era; e isso basta. Além disso, o depoimento do menor com 16 anos completos é pleno, tendo ele plena capacidade de testemunhar (artigo 208 do CP e artigo 447 do CPC), de sorte que a assistência de maior de idade ou de responsável era mesmo dispensável.

De qualquer forma, a presença da irmã demonstrou que ninguém coagiu a vítima a depor contra o agressor. Aliás, não haveria motivo para isso, nem há indícios mínimos de que escrivão inventaria depoimento contra o agressor, e incriminar pessoa que nem ao menos conhecia.

Em que pese a alegação da Defesa de que Tainara teria inimizade com réu e suposto interesse na sua condenação, seu depoimento, frise-se, não está isolado. É corroborado e harmônico com o depoimento de guardas municipais, que ouviram da vítima que o réu estava a mantendo preso dentro do apartamento, e a ameaçando, e que já fora agredida em datas pretéritas.

Pondere-se, neste passo, que os guardas não conheciam o acusado, e não teriam motivos para mentir e incriminá-lo falsamente, afastando-se a possibilidade de injusta acusação.

Assim, já se decidiu: "Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois

negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas" (TJRJ - AC. - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

O acusado alega que não impediu a vítima de sair do apartamento, pois ela tinha cópia da chave e poderia sair à hora que quisesse, bem como ela tinha celular com acesso à internet.

Sua versão não prevalece. Se naquele momento tivesse acesso a chaves e celular, a vítima não teria escrito o bilhete de socorro e o jogado pela janela.

O bilhete de socorro escrito pela vítima e atirado pela janela indica seu estado de medo, estado que, diante de ameaças de morte, inclusive com faca (caso ela terminasse o relacionamento), fizeram-na tomar a atitude em defesa de sua integridade física.

A Defesa alega que o réu guardou a chave, porque a vítima estava com crise de ansiedade, causada pela discussão, e não teria condições de sair sozinha, pela sua segurança.

As provas, todavia, demonstraram o contrário.

O histórico de agressões narrado pela vítima e testemunhas; o bilhete de socorro da vítima atirado pela janela; a necessidade de forçar a entrada no apartamento; o réu deitado na cama com a vítima, com o braço sobre ela; a chave do imóvel encontrada no bolso do acusado; as declarações da vítima, de que o réu a impedia de sair do local, ameaçando-a de morte e apontando faca, e de que a mandou ficar quieta quando guardas chamaram; e as declarações dos guardas, a confirmar todos os fatos, são elementos contundentes de que Ailton dolosamente privou a liberdade de J.S.S., mediante cárcere privado, valendo-se de ameaças de morte, inclusive com faca, por ela ter manifestado a vontade de terminar o relacionamento.

Em suma, as alegações negatórias do réu e da defesa ficaram isoladas, incapazes de infirmar as consistentes provas produzidas nos autos.

Dada a harmonia da prova, a condenação de Ailton por cárcere privado se imporá na forma do artigo 148, § 1º, incisos I e IV, do Código Penal.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, considero, ao ponderar as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal (CP), com destaque à culpabilidade, às circunstâncias do delito e à personalidade e conduta social do agente:

- 1) O fato de o réu cometer o delito valendo-se de grave ameaça de morte contra a vítima, usando até mesmo uma faca para intimidá-la e mantê-la cativa [+ 1/6].
- 2) Os aspectos negativos de sua personalidade e conduta e histórico de vida, diante do histórico de agressões e ameaças domésticas praticadas contra vítima (histórico logo e confirmado pela irmã da vítima, pela própria ofendida e por guardas que a ouviram no local dos fatos) [+ 1/6].
- 3) Verifico ainda que o réu incidiu não em uma, mas em duas qualificadoras (vítima companheira e menor de 18 anos), de modo que a pena mínima será majorada. A primeira qualificadora circunscreve a tipificação em si, e a segunda se imporá como circunstância judicial, implicando majoração sobre a pena mínima de base [+ 1/6].

Parece necessária, aqui, para a real prevenção e reprovação da conduta, na forma do artigo 59 do CP, a majoração de 1/2 (3 x 1/6; cf. acima), aplicada sobre o piso abstrato. Analisando as circunstâncias judiciais e sopesando os aspectos acima, o

aumento da primeira fase será mesmo imperativo, na fração de 1/2 sobre a pena-base, fixando-se a pena em 3 anos de reclusão. É a pena-base.

Na segunda fase, é de considerar que o réu apresenta duas reincidências simples (Proc. 0002126-68.2012.8.26.0142, por tráfico, e 0002472-19.2012.8.26.0142, por porte ilegal de arma; vide fls. 262/264, ambos em cumprimento de pena).

Considero a majoração de 1/6 para cada reincidência (para a simples, aplica-se 1/6; para a específica, 1/4); logo, implicando o aumento de 2/6 (= 1/3).

Assim, aplicada aqui a fração de 1/3 (2 x 1/6) sobre a pena-base, tem-se, nesta segunda fase, o tantum punitivo de 4 anos de reclusão.

Na terceira fase nada há que considerar, mantendo-se a pena anterior.

Não há previsão de multa.

FINALIZAÇÃO:

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado. Não há como fixar regime mais brando, nem aplicar pena alternativa ou sursis, sendo o regime fechado efetivo o único apto à eficiente repressão e prevenção da conduta. As circunstâncias judiciais (v. acima) são desfavoráveis ao réu, houve violência e este ostenta dupla reincidência.

O tempo de prisão provisória não influirá no regime de pena, quer pelo motivo já exposto, quer porque não atribuído (apenas) com base no intervalo de pena (numérico-abstrato), mas com base nas circunstâncias judiciais expostas em primeira fase (art. 33, § 3.º, do CP). É que a detração cognitiva imposta pela lei (não se trata, ressalte-se, da detração executória, endereçada ao juízo das execuções penais) não modificará aqui o regime fixado como inicial, pois que este não se baseou em intervalos numéricos, mas nas circunstâncias concretas, objetivas e subjetivas, conforme apontado em primeira fase dosimétrica.

Indefiro a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária ao acusado.

O deferimento da gratuidade processual aqui estará condicionado à efetiva comprovação da necessidade. De consignar que a presunção constante do artigo 99, §3º, do NCPC é meramente relativa, e pode o juízo indeferi-lo.

Até porque, por se tratar juridicamente de taxa judiciária (de natureza tributária), a matéria não fica na livre disponibilidade das partes. Em decorrência justamente da natureza tributária da taxa judiciária, o juízo não é mero espectador, devendo apreciar o caso concreto, para deferir ou não o benefício.

Nos autos, ausente a comprovação da necessidade e tratando-se de réu assistido por defensor particular, não há presunção de hipossuficiência econômica.

Nesse sentido:

"(...) Justiça Gratuita. Indeferimento. Ausência de dados precisos sobre a situação financeira do peticionário, que, assistido por defensores particulares, não goza da presunção relativa de hipossuficiência material.(...).\" (Revisão Criminal 2146523-15.2021.8.26.0000. 5º Grupo de Direito Criminal. Rel. Des. Alcides Malossi Júnior. Data do julgamento: 03/11/2021)."

Posto isso, JULGO A AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

CONDENO o réu AILTON CÉSAR GONÇALVES DA SILVA como incurso no artigo 148, §1º,

incisos I e IV, do Código Penal (cárcere privado qualificado) à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu AILTON CÉSAR GONÇALVES DA SILVA com relação à prática do delito do artigo 147, cumulado com o art. 61, inciso II, "f", do Código Penal, com fundamento no artigo 107, IV, do Código Penal (decadência).

O réu fica ainda condenado às custas (100 Ufesps) e às demais despesas do processo (diligências de Oficial). Não será deferida a gratuidade processual.

Fixo indenização à vítima, à luz do previsto no CPP, art. 387, IV, e dos pedidos do MP, em denúncia e em alegações finais orais. Observo que os danos morais são in re ipsa, e os fatos restaram comprovados na instrução. Nesse sentido, há que observar o TEMA 983 do STJ.

Fica AILTON CÉSAR GONÇALVES DA SILVA condenado a pagar à vítima R\$ 15.000,00 (dez mil reais) como reparação mínima de danos morais, com correção monetária desde a sentença, e com juros e 1%/mês desde a data do fato.

O réu não terá o direito de recorrer em liberdade, haja vista a solidificação, por meio da instrução e da sentença, dos requisitos necessários à prisão preventiva. As circunstâncias do delito, recordadas em primeira fase de dosimetria, além da reincidência, fazem que, em nome do resguardo da ordem pública, aguarde preso. A imperiosidade da prisão não perdeu atualidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu: "(...) A necessidade da segregação fica reforçada na hipótese dos autos, em que sobreveio a sentença, tendo o paciente respondido a toda a ação penal preso, uma vez que a existência de édito condenatório enfraquece sua presunção de não culpabilidade, de modo que se mostra adequada a manutenção da prisão. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública." (HC 454.752/SC, Rel.Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Órgão Julgador: Quinta Turma, julgado em 07/08/2018).

Expeça-se de imediato a guia de recolhimento provisória do acusado.

Transitada em julgado a sentença, se mantida, façam-se os ofícios (IIRGD e Eleitoral), expeça-se a guia de execução definitiva, cobrem-se as custas processuais e recomende-se onde estiver preso.

OBJETO:

Oficie-se à delegacia para que autorizada a destruição do bilhete apreendido.

Nos termos do artigo 201 do Código de Processo Penal, a vítima será intimada, por meio de sua genitora, por carta (ou por meio mais célere), seguindo cópia integral da sentença.

Intime-se o réu pessoalmente.

Dê-se ciência ao MP.

Arquive-se oportunamente.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

Hortolândia, 4 de outubro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA